

刑法
No.74

R4-5

(配点: 2)

月	日
月	日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの個数を後記1から5までの中から選びなさい。

- ア. 甲は、乙（10歳）の性器を指で触るわいせつな行為を行った。この場合、乙が同意していたのであれば、甲に不同意わいせつ罪は成立しない。(改)
- イ. 甲は、不同意わいせつの目的を隠し、家まで送ると偽って乙を自動車に乗せて走り出し、途中でその目的に気付いた乙が降りたいと言ったにもかかわらず、同車を走行させ続けた。この場合、乙は、乗車時点では乗車に同意しているから、乙が降りたいと言った時点以降についてのみ、甲に監禁罪が成立する。(改)
- ウ. 甲は、乙と保険金詐欺を共謀し、過失による自動車事故を装い、甲運転の自動車を乙運転の自動車に故意に追突させて、乙に傷害を負わせた。この場合、乙が傷害を負わされることに同意している以上、甲に傷害罪は成立しない。
- エ. 甲は、刑務所に服役したいと考えている乙と口裏を合わせ、乙の同意を得て、司法警察員に対し、乙に現金を窃取された旨の虚偽の被害届を提出した。この場合、乙の同意がある以上、甲に虚偽告訴罪は成立しない。
- オ. 甲は、現金自動預払機を利用する客のキャッシュカードの暗証番号を盗撮する機器を設置する目的で、行員が常駐しない銀行出張所内に立ち入った。この場合、甲による立入りの外観が一般の利用客のそれと異なることがなければ、甲に建造物侵入罪は成立しない。
1. 1個 2. 2個 3. 3個 4. 4個 5. 5個

Na74	被害者の同意	正答率
R4-5	正 解	87%

ア 誤っている

本記述は、乙が同意していたのであれば、甲に不同意わいせつ罪は成立しないとしている点で、誤っている。

不同意わいせつ罪（176条3項）は、「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者（当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。）」に成立する。13歳未満の児童は、性的行為の意味を正しく理解できないのが一般的であるため、その承諾は一律に無効となる。つまり、被害者が13歳未満の場合、その承諾があっても、不同意わいせつ罪が成立する。本記述の甲の行為は不同意わいせつ罪（同条3項）の構成要件に該当する。乙（10歳）の同意は構成要件該当性に影響しない。したがって、乙が同意していたとしても、甲には、不同意わいせつ罪が成立する。

イ 誤っている

本記述は、乙は、乗車時点では乗車に同意しているから、乙が降りたいと言った時点以降についてのみ、甲に監禁罪が成立するとしている点で、誤っている。

最決昭33.3.19。判例は、被害者をD地点に連れて行く信じさせてA地点で車に乗せて走り出したが、B地点で車が違う方向に進路を変更したので被害者がだまされたと気づき、C地点で車外に逃れた事案において、AB間を含むAからC地点までの間の監禁罪の成立を認めている。その理由として、判例は、220条にいう「監禁」は、暴行または脅迫によってなされる場合だけではなく、偽計によって被害者の錯誤を利用してなされる場合をも含むものと解すべきであるということを出している。本判例は、可能的自由説に立つものと理解されている（なお、本記述と同様の事案で監禁罪の成立を認めたものとして、広島高判昭51.9.21がある。）。本記述の甲は、不同意わいせつの目的を隠し、家まで送ると偽って乙を自動車に乗せて走り出し、途中でその目的に気付いた乙が降りたいと言ったにもかかわらず、同車を走行させ続けたのであるから、偽って乙を自動車に乗せて走り出した時点以降から「監禁」したといえる。したがって、甲には、乙が降りたいと言った時点以降ではなく、偽って乙を自動車に乗せて走り出した時点以降から監禁罪が成立する。

ウ 誤っている

本記述は、乙が傷害を負わせることに同意している以上、甲に傷害罪は成立しないとしている点で、誤っている。

最決昭55.11.13（百選I22事件）。判例は、本記述と同様の事案において、「被害者が身体傷害を承諾したばあいには傷害罪（204条）が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合せて決すべきものであるが、本件のように、過失による自動車衝突事故であるかのように装い保険金を騙取する目的をもって、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせたばあいには、右承諾は、保険金を騙取するという違法な目的に利用するために得られた違法なものであって、これによって当該傷害行為の違法性を阻却するものではない」としている。本記述の甲の行為は傷害罪の構成要件に該当する。保険金騙取という違法な目的であるため、同意による違法性阻却は認められない。したがって、乙が傷害を負わされることに同意していたとしても、甲には、傷害罪が成立する。

エ 誤っている

本記述は、乙の同意がある以上、甲に虚偽告訴罪は成立しないとしている点で、誤っている。

大判大元12.20。判例は、本記述と類似の事案において、虚偽告訴罪（172条）が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、申告に告訴者・被告訴者の一致が見られれば捜査の端緒として重視されやすく、国家の司法作用をかなり侵すこと、国家法益に対する罪である以上、同意のある虚偽告訴も構成要件に該当するということを挙げている。本記述の甲の行為は、虚偽告訴罪の構成要件に該当する。乙の同意を得ていても構成要件該当性には影響しない。したがって、乙の同意があっても、甲には、虚偽告訴罪が成立する。

オ 誤っている

本記述は、甲による立入りの外観が一般の利用客のそれと異なることがなければ、甲に建造物侵入罪は成立しないとしている点で、誤っている。

最決平19.7.2（百選Ⅱ18事件）。判例は、本記述と同様の事案において、「現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入ったものであり、そのような立入りが同所の管理権者である銀行支店長の意思に反するものであることは明らかであるから、その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客のそれと特に異なるものでなくても、建造物侵入罪が成立する」としている。このように判例は、一般に開放されている場所（社会的営造物）への違法目的の立入りについては管理権者の包括的同意を認めず、建造物侵入罪の成立を認めるものと理解されている。本記述の甲は、盗撮機器の設置という違法目的を有していることから、銀行支店長の包括的同意は認められない。したがって、甲による立入りの外観が一般の利用客のそれと異なることがなくても、甲には、建造物侵入罪が成立する。

以上により、誤っている記述はア、イ、ウ、エ、オの5個であり、したがって、正解は肢5となる。